

0006630-24.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... ido verificar fato relacionado a notícia de tráfico e, em seguida, levado o suspeito para a delegacia. Ali, o réu Carlos Eduardo se fez presente, dizendo que seria namorado de Jone e que também estaria praticando tráfico, mas do outro lado da praça, a fim de pagar dívida de ambos. Carlos Eduardo queria trocar as drogas que portava pela liberdade de Jone, dispondo-se a ir ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0006630-24.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006630-24.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107234/2021 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 17433504 -

DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 985/21/050 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2107234 - DEL.SEC.BAURU PLANTÃO, 2107234 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 985/21/050 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO ALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

CARLOS EDUARDO ALVES foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 19 de abril de 2.021, por volta das 22h11, na Praça Rui Barbosa, Centro, nesta cidade, em conjunto com o corréu Jone Elias dos Santos, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 12,52 gramas de maconha, 0,60 gramas de crack e 0,79 gramas de cocaína, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Citado (fls. 221), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 237/239.

A denúncia foi recebida por despacho datado de 26 de julho de 2.021 (fls. 156/158). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 265/281). Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência parcial da ação penal (fls. 285/288).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 291/313, alegando que: 1)- a versão dos policiais é pouco crível, pois não é possível que Carlos fosse vender drogas introduzidas em seu ânus, pois o local é uma praça no centro da cidade com bastante movimento; 2)- os depoimentos policiais não são suficientes para a condenação; 3)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, ao regime aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pediu a absolvição e, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 37/38 e pelo laudo pericial de fls. 119/124 (dezoito porções de maconha com peso de 12,52 gramas, três porções de cocaína com peso de 0,79 gramas e doze porções de crack com peso de 0,60 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Interrogado na polícia, ele declarou ter ficado sabendo que seu namorado Jone havia sido preso, quando na posse de drogas, na Praça Rui Barbosa. Compareceu espontaneamente na delegacia, para se entregar. O entorpecente que estava com Jone lhe pertencia. Havia lhe pedido para pegá-la com um terceiro desconhecido e lhe trazer. Não queria que Jone fosse preso injustamente e, por isso, veio assumir a responsabilidade pelo material. Afirmou para os policiais que estavam na posse de várias trouxinhas de maconha escondidas no ânus. Foi ao banheiro da delegacia e as retirou (fls. 23).

Interrogado na polícia, o corréu Jone afirmou que estava na Praça Rui Barbosa conversando com uma pessoa. Quando os policiais militares se aproximaram, jogou no chão algumas pedras de crack, as quais transportava para Carlos Eduardo. Tem um caso amoroso com Carlos Eduardo. As drogas seriam vendidas para pagar dívidas de Carlos (fls. 12).

Em juízo, a testemunha Marcelo Wanderlei Barreira, policial militar, relatou ter ido verificar fato relacionado a notícia de tráfico e, em seguida, levado o suspeito para a delegacia. Ali, o réu Carlos Eduardo se fez presente, dizendo que seria namorado de Jone e que também estaria praticando tráfico, mas do outro lado da praça, a fim de pagar dívida de ambos. Carlos Eduardo queria trocar as drogas que portava pela liberdade de Jone, dispondo-se a ir preso no lugar deste. Disse-lhe que isso seria impossível. Informou ao delegado a respeito, e ele determinou que Carlos Eduardo fosse ao banheiro, para revista. No banheiro, o próprio Carlos retirou dezoito porções de maconha do ânus. Momentos antes, Jone havia sido preso na Praça Rui Barbosa, após jogar um saco contendo doze pedras de crack e três pinos de cocaína. Jone portava, na ocasião, cerca de vinte e quatro reais, no bolso. Jone ficou o tempo todo quieto e nada respondeu. Carlos Eduardo se apresentou aos policiais na calçada da delegacia. Ele explicou que estavam vendendo drogas para pagar uma dívida (fls. 266/270).

A testemunha Rodrigo Fabiano Ortiz, também policial militar, relatou que, durante patrulhamento na área central da cidade, observou dois indivíduos na praça. Os policiais adentraram no local com a viatura. O primeiro indivíduo jogou um objeto no chão. Depois, verificou-se que nele se continham porções de droga e vinte e quatro reais. O indivíduo foi detido e levado para a delegacia. Ali, no momento em que o preso era desembarcado da viatura, o réu Carlos Eduardo se apresentou. Ele relatou ser amasiado com Jone e que teria que ser preso junto com este último ou no lugar dele. Informou-o de que não era possível. Carlos Eduardo insistiu e admitiu que trazia consigo certa quantidade de entorpecente, no ânus. Cientificou o delegado a respeito, e ele determinou que Carlos Eduardo fosse revistado no banheiro. O réu disse não ser necessária a revista e, por si próprio, adentrou no

banheiro e retirou dezoito porções de maconha. Carlos Eduardo lhe afirmou que também estava na praça, mas um pouco mais longe, e que viu a prisão de Jone e não se aproximou. Ele também confirmou que estava vendendo droga junto com Jone, visando pagar uma dívida. As dezoito porções de maconha estavam em forma de terço, prontas para venda, "várias bolinhas do mesmo tamanho". Carlos Eduardo explicou que as retirava, cortava e vendia (fls. 272).

Interrogado em Juízo, o réu preferiu o silêncio (fls. 279).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

Em solo policial, o réu confessou a prática do tráfico (fls. 23), assim como seu comparsa Jone (fls. 12).

A confissão extrajudicial é relevante elemento de convicção.

Nesse sentido:

"É sabido que a confissão deve ser avaliada pela força de convencimento que nela se contém, e não pelo local onde ela é prestada. Vale dizer, a confissão extrajudicial corroborada pela palavra de testemunhas, bem como por outros elementos objetivos de prova, não pode ser invalidada pela retratação, em pretório, sem qualquer explicação plausível para a confissão policial e com nova versão totalmente inverossímil." (TJSP, Apelação n. 9230875-35.2008.8.26.0000, rel. Silmar Fernandes, j. 10/05/2012).

No caso, a confissão está corroborada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, colhidos em juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, as testemunhas afirmaram ter visto, na Praça Rui Barbosa, Jone dispensar um saco, no qual havia porções de crack e cocaína e dinheiro, bem como que, ao desembarcá-lo da viatura na delegacia, o acusado Carlos Eduardo ali espontaneamente se apresentou, admitiu a prática de tráfico em comparsaria com o corréu e, no banheiro da delegacia, retirou dezoito porções de maconha de seu ânus. As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

A propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Ademais, nenhum elemento de convicção foi produzido a dar conta de que, no caso, os policiais teriam algum motivo para falsear a verdade em detrimento de pessoa que sequer conheciam, e mesmo de que, ainda que não tivessem qualquer motivo para tanto, alteraram a realidade dos fatos.

Assim, não colhe a tese de que a prova é frágil.

Por outro lado, não há dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico.

É necessária a análise conjunta dos requisitos previstos no art. 28, §2º da Lei 11.343/06 para a distinção entre o usuário e o traficante.

Na hipótese "sub judice", o réu se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia logo em seguida a prisão de Jone, admitiu perante os policiais que praticava o tráfico junto com este último para pagarem uma dívida e, levado ao banheiro, retirou do próprio ânus dezoito porções de maconha, em forma de terço e

embaladas de maneira condizente com o comércio no varejo.

Não se olvide, ainda, que a praça Rui Barbosa, onde ambos os acusados estavam, é conhecido ponto de tráfico do centro da cidade de Bauru.

Logo, a outra conclusão não se pode chegar senão à de que o réu portava as drogas para destiná-las a terceiros.

Confira-se o seguinte julgado:

"Portanto, para a correta tipificação da conduta, é fundamental que o Julgador verifique as particularidades do delito, atentando-se à natureza e quantidade da droga, bem como ao local em que se desenvolveu a ação delitiva, às circunstâncias nas quais estava o agente. In casu, foram arrecadadas 3,60g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como "crack", sendo certo que a aludida droga estava separada em vinte e uma porções, propícias ao comércio." (TJ-MG, Apelação Criminal 10481100114174001, Des. Rubens Gabriel Soares - Relator).

Não colhe o argumento da defesa, no sentido de ser pouco crível que o acusado fosse retirar porções de maconha de seu ânus para em seguida comercializá-las em plena praça pública.

Primeiro, deve-se ponderar que, certamente, o réu deixou tais porções de forma superficial em seu ânus, com o que era possível retirá-las de maneira mais fácil a fim de servir usuários que o procuravam.

Segundo, não se pode olvidar que a Praça Rui Barbosa, justamente por ser movimentada, é ladeada por diversos estabelecimentos comerciais, todos por certo dotados de banheiros.

A própria praça tem banheiros públicos.

Sendo assim, manter as drogas junto ao ânus não somente permitia menor risco de êxito de eventual abordagem policial, como também possibilitava entrega relativamente simples ao adquirente, bastando que o acusado se dirigisse a um dos banheiros das proximidades de onde estava para disponibilizar o material.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Ao revés, é de rigor a condenação do réu por crime de tráfico.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, porém, a absolvição se impõe. Isto porque não se demonstrou qualquer circunstância capaz de evidenciar a existência de "animus associativo" entre os envolvidos, nem que o vínculo entre eles era dotado de permanência e estabilidade.

Trata-se, pois, no caso, de simples coautoria, pois sequer é possível descartar que a reunião dos acusados para a prática criminosa tenha se dado de forma isolada. Nessas circunstâncias, não se caracteriza o delito de associação para o tráfico, que exige mais do que a simples coautoria.

Nesse sentido:

"Com relação ao crime de associação (art. 35), em que pese o inconformismo ministerial, tal delito não restou minimamente demonstrado pela prova dos autos, como judiciosamente analisado pela douta Magistrada sentenciante. A conduta descrita no art. 35 da Lei n. 11.343/06 vem representada pelo verbo 'associar', que significa agregar-se, unir-se. Essa associação, no entanto, deve observar um mínimo de estabilidade. Não se confunde, assim, com o mero concurso de agentes. O crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os agentes. E sem a prova efetiva de uma verdadeira associação permanente e duradoura voltada à prática do tráfico ilícito de drogas, não há como sustentar um decreto condenatório. Tal qual o crime de quadrilha ou bando, a associação para a traficância exige elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. O de associação em especial para o crime de tráfico. É delito autônomo e dispensa até

a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação. Porém, inadmissível que toda e qualquer comparsaria para a prática delituosa, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância." (TJSP, Apelação Criminal n. 0001922-45;2009.8.26.0363, rel. Newton Neves, j. 1º/02/2011).

Em suma, a condenação do réu por tráfico e sua absolvição pelo delito de associação são medidas de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes (fls. 76/77).

Diante disso, fixa-se a pena no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destaque-se que a quantidade de droga apreendida não era das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa.

Outrossim, inexistem elementos de convicção a apontar que Carlos Eduardo se dedicava a atividade criminosa ou era integrante de organização criminosa.

Ao contrário, as circunstâncias indicam tratar-se de traficante ocasional, na medida em que, segundo o afirmado pelos réus, a prática criminosa se dava visando pagar uma dívida (interpretando-se "a contrariu sensu", pode-se concluir que, antes da dívida e depois que ela fosse quitada, o agente não cometia tráfico e nem voltaria a fazê-lo).

Afigura-se justo deferir a diminuição no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas não foram das mais elevadas. Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no Habeas Corpus n. 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes e pequenas quantidades de drogas e de dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto. Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a

redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Carlos Eduardo Alves como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução, bem como para absolvê-lo da acusação de cometimento do delito descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Diante da pena imposta, expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.

Bauru, 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA